

## <제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제2절 청구의 후발적 병합>

### I. 청구의 변경

#### 1. 의의[민소법 제262조]

- 청구의 변경이란 원고가 소송계속 중에 소송물인 청구를 변경하는 것을 말한다. 이는 소의 제기 후에 새로운 청구를 추가하거나 종전의 청구를 다른 청구로 갈음하는 형태로 나타나며, 분쟁의 일거 해결과 소송경제 도모를 목적으로 한다. 민사소송법 제262조는 청구의 기초에 변경이 없는 한 사실심의 변론종결 시까지 청구를 변경할 수 있음을 명시하고 있다.

#### 2. 청구변경의 방법

##### (1) 청구취지의 변경

- 심판의 대상인 결론 부분을 변경하는 것이다. 금전지급청구에서 금액을 증액하거나 감액하는 경우, 또는 특정물의 인도를 구하다가 그 가액의 배상을 구하는 형태가 이에 해당한다.

##### (2) 청구원인의 변경

- 청구를 뒷받침하는 구체적인 사실관계나 법률적 근거를 변경하는 것이다. 동일한 대여금 청구 내에서 대여일자를 정정하거나, 불법행위로 인한 손해배상을 청구하다가 채무불이행으로 인한 손해배상으로 근거 법조를 바꾸는 경우를 포함한다.

##### (3) 공격방어방법의 변경

- 청구의 변경은 소송물 자체의 변경을 의미하므로, 단순히 소송물을 유지한 채 새로운 증거를 제출하거나 사실적 주장을 보충하는 공격방어방법의 변경과는 구별된다. 청구의 기초가 동일하더라도 소송물이 달라지지 않는다면 이는 청구의 변경이 아닌 자료의 보강에 불과하다.

#### 3. 청구변경의 형태

##### (1)교환적 변경

- 종전의 청구를 철회하고 새로운 청구로 갈음하는 것이다. 이는 구청구의 취하와 신청구의 제기가 결합된 형태이다. 실무상 구청구에 대한 소취하의 효력이 발생하므로 피고의 동의 여부가 문제될 수 있으나, 청구기초의 동일성이 인정되는 한 피고의 동의 없이도 가능하다는 것이 통설이다.

##### (2)추가적 변경

- 종전의 청구를 유지하면서 새로운 청구를 덧붙이는 것이다. 이는 청구의 객관적 병합이 사후적으로 발생하는 형태이며, 단순·선택적·예비적 병합의 모습으로 나타날 수 있다.

##### (3)변경형태가 불분명한 경우

- 원고의 의사가 교환적인지 추가적인지 명확하지 않을 때 법원은 석명권을 행사하여 이를 명확히 해야 한다. 일반적으로 원고에게 유리하도록 추가적 변경으로 해석하는 경향이 있으나, 전후 사정에 비추어 종전 청구를 유지할 의사가 없음이 명백하다면 교환적 변경으로 취급한다.

#### 4. 청구변경의 요건

##### (1)동종의 소송절차

- 기존의 소송절차와 변경된 새로운 청구의 소송절차가 같아야 한다. 민사소송 중에 가사소송이나 행정소송으로 변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

##### (2)공통의 관할권

- 변경된 신청구가 그 법원의 관할에 속해야 한다. 다만, 민사소송법 제25조의 관련재판적 규정에 의하여 본래의 청구에 관할권이 있다면 신청구에 대해서도 관할권이 인정될 수 있다.

##### (3)청구기초의 동일성

- 가장 핵심적인 요건으로, 신청구가 구청구와 동일한 사회적 사실관계나 경제적 이익을 바탕으로 해야 한다. 양 청구의 이익관계가 밀접하여 구청구의 심리자료를 신청구의 심리에 그대로 활용할 수 있는 경우에 인정된다.

##### (4)소송절차를 현저히 지연시키지 않을 것

- 청구의 변경으로 인하여 새로운 증거조사가 광범위하게 필요하게 되어 소송의 완결이 늦어지는 경우에는 허용되지 않는다. 이는 피고의 방어권 보호와 신속한 재판을 위한 요건이다.

##### (5)사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

- 청구의 변경은 1심 또는 항소심에서만 가능하다. 상고심은 법률심이므로 청구의 변경이 허용되지 않는다. 반드시 변론종결 전에 신청되어야 한다.

#### 5. 청구변경의 절차

- 청구의 변경은 서면으로 신청하는 것이 원칙이다. 변경신청서에는 변경된 청구취지와 청구원인을 명확히 기재해야 하며, 이 서면은 피고에게 송달되어야 한다. 다만, 변론기일에서 말로 변경하고 피고가 이에 대해 이의 없이 응한 경우에는 구술에 의한 변경도 유효할 수 있다.

#### 6. 청구변경의 심판[민소법 제263조]

##### (1)청구변경의 적법성 심사와 신청구심판

- 법원은 우선 청구변경의 요건을 심사하여 부적법한 경우 결정으로 각하한다. 요건을 갖춘 경우 신청구를 대상으로 심리를 진행한다. 교환적 변경의 경우 구청구는 심판 대상에서 제외되며, 추가적 변경의 경우 병합소송의 원리에 따라 심판한다.

##### (2)청구변경의 간과판결

- 원고가 청구변경을 신청하였음에도 법원이 이를 간과하고 종전 청구에 대해 판결한 경우 이는 재판의 누락에 해당한다. 이 경우 누락된 부분은 여전히 법원에 계속된 상태로 남게 된다.

##### (3)항소심의 판결주문

- 항소심에서 청구가 교환적으로 변경된 경우, 1심 판결은 실효된다. 따라서 항소심 법원은 1심 판결을 취소하고 신청구에 대하여만 판결을 내려야 한다. 신청구가 이유 있다면 신청구 인용 판결을, 이유 없다면 신청구 기각 판결을 내린다.

### II. 중간확인의 소

#### 1. 의의[민소법 제264조]

- 중간확인의 소는 소송계속 중 본래의 청구의 당부와 관련하여 선결적 법률관계에 대하여 다툼이 있는 경우, 당사자가 그 법률관계의 확정을 위하여 추가로 제기하는 확인의 소를 말한다. 기판력의 범위를 확장하여 분쟁을 근본적으로 해결하는 데 목적이 있다.

#### 2. 요건

##### (1)동종의 소송절차

- 본소와 중간확인의 소는 같은 소송절차에 따라 심판될 수 있어야 한다.

## (2) 공통의 관할권

- 본소가 계속된 법원에 중간확인의 소에 대한 관할권이 있어야 한다. 관련재판적에 의해 관할이 발생할 수 있다.

## (3) 다름이 있는 선결적 법률관계의 확인

- 본소 청구의 재판 결과가 그 법률관계의 존부에 달려 있어야 한다. 예를 들어 소유권이전등기청구 소송 중에 그 전제가 되는 매매계약의 유효 여부를 확인하는 경우이다. 단순히 사실관계의 확인은 대상이 되지 않는다.

## (4) 다른 법원의 전소관할에 속하지 않을 것

- 확인하고자 하는 법률관계가 다른 법원의 전속관할에 속하는 경우에는 제기할 수 없다.

## (5) 본래의 소가 사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

- 청구의 변경과 마찬가지로 항소심 변론종결 전까지만 제기가 가능하다.

## 3. 절차

- 중간확인의 소는 독립된 소의 제기이므로 소장의 형식에 준하는 서면을 제출해야 한다. 다만, 기존 소송절차를 이용하므로 인지대 등에 있어서 일정한 혜택이 있을 수 있다.

## 4. 심판

- 법원은 본소와 중간확인의 소를 병합하여 심리하고 하나의 판결로 선고해야 한다. 중간확인의 소가 부적법하면 각하하고, 적법하면 본소의 선결문제로서 판단함과 동시에 주문에서 그 존부를 확정한다.

## III. 반소

### 1. 반소의 의의

#### (1) 개념[민소법 제269조]

- 반소란 소송계속 중에 피고가 원고를 상대로 동일한 소송절차 내에서 제기하는 독립된 소를 말한다. 피고가 수세적 방어에 그치지 않고 공세적 공격을 가하는 형태이다.

#### (2) 인정취지

- 동일한 당사자 사이의 밀접한 관련이 있는 청구들을 하나의 절차에서 심리함으로써 심리의 중복을 피하고 판결의 모순을 방지하며 소송경제를 달성하기 위함이다.

### 2. 반소의 법적 성질

#### (1) 독립한 소

- 반소는 본소에 부수된 방어방법이 아니라 독립된 소이다. 따라서 본소가 취하되더라도 피고의 동의가 없는 한 반소는 소멸하지 않고 독자적으로 존속한다.

#### (2) 반소의 당사자

- 원칙적으로 본소의 피고가 원고가 되고, 본소의 원고가 피고가 된다. 예외적으로 예비적 피고 추가 등 특수한 경우에 제3자를 포함하는 반소가 논의되기도 하나 원칙은 본소 당사자 간의 소송이다.

### 3. 반소의 모습

#### (1) 단순반소와 예비적 반소

- 피고가 조건 없이 제기하는 것이 단순반소이고, 본소가 인용될 것을 대비하거나 기각될 것을 대비하여 제기하는 것이 예비적 반소이다.

#### (2) 재반소

- 원고가 피고의 반소에 대하여 다시 반소를 제기하는 것이다. 이론적으로는 가능하나 소송절차의 복잡화를 방지하기 위해 실무상 엄격히 제한되거나 본소의 청구변경으로 처리되는 경우가 많다.

### 4. 반소의 요건

#### (1) 동종의 소송절차

- 본소와 반소가 같은 종류의 소송절차를 따라야 한다.

#### (2) 공통의 관할

- 본소 법원에 반소에 대한 관할권이 있어야 한다. 민사소송법 제269조 제2항은 반소가 다른 법원의 전속관할에 속하지 않는 한 관할권이 인정됨을 명시하고 있다.

#### (3) 상호관련성

- 반소청구가 본소청구 또는 본소의 방어방법과 법률상·사실상 밀접한 관련이 있어야 한다. 관련성이 없는 반소는 무분별한 소송 지연을 초래할 수 있기 때문이다.

#### (4) 본소절차를 현저히 지연시키지 않을 것

- 반소 제기로 인해 기존 소송의 완결이 늦어지지 않아야 한다. 특히 항소심에서의 반소 제기는 상대방의 심급의 이익을 해칠 우려가 있어 원고의 동의나 반소 청구의 기초가 1심에서 충분히 심리된 경우 등으로 제한된다.

#### (5) 본소가 사실심에 계속되고 변론종결 전일 것

- 상고심에서는 반소를 제기할 수 없다.

### 5. 반소의 절차

#### (1) 반소의 제기

- 반소장 서면을 제출해야 하며, 인지를 첨부해야 한다. 반소장은 원고에게 송달되어야 소송계속의 효과가 발생한다.

#### (2) 반소요건과 일반소송요건의 조사

- 법원은 반소의 특수 요건뿐만 아니라 당사자능력, 소의 이익 등 일반적 소송요건을 모두 갖추었는지 직권으로 조사한다.

### 6. 반소의 심판

#### (1) 본안심판

- 법원은 본소와 반소를 병합하여 심리한다. 판결 주문에서 본소와 반소에 대하여 각각 판단을 내려야 한다. 다만, 본소와 반소가 동일한 목적물을 대상으로 하거나 상계와 관련되는 등 관계가 밀접할 경우 논리적 일관성을 유지해야 한다.

## (2) 반소의 취하

- 피고는 본안에 대한 응소가 있기 전까지 자유롭게 반소를 취하할 수 있다. 본소가 취하된 후에도 반소를 유지할 수 있으나, 본소가 취하되었으므로 반소도 취하하겠다는 의사표시가 있는 경우 절차는 종료된다.

## (3) 채권자취소권과 반소와의 관계

- 피고가 본소에 대한 방어방법으로 채권자취소권을 행사하며 반소를 제기하는 경우, 판례는 채권자취소의 효과를 소송상 주장하기 위해서는 반드시 반소 또는 독립된 소의 형태를 갖추어야 한다고 본다.

## IV. 결론

- 청구의 후발적 병합 제도는 소송계속 중에 발생하는 새로운 분쟁 요소나 방어의 필요성을 기존 절차 내로 수용함으로써 법률관계의 종합적 해결을 가능케 한다. 청구의 변경은 원고에게, 반소는 피고에게 소송의 전략적 구성을 허용하며, 중간확인의 소는 판결의 전제가 되는 법률관계를 명확히 확정 짓는 도구가 된다. 이러한 제도들은 각기 엄격한 요건을 두고 있는데, 이는 소송절차의 안정성과 상대방의 방어권 보장, 재판의 신속성이라는 가치를 조화시키기 위함이다. 특히, 항소심에서의 변경이나 반소 제기는 심급의 이익 침해 가능성이 크므로 더욱 신중한 사법적 판단이 요구된다. 결과적으로 후발적 병합의 적절한 운용은 당사자 간의 실질적 평등을 구현하고 사법 자원의 효율적 배분을 가능하게 하는 민사소송법의 중추적 기능을 담당한다.